

1500432-46.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... cooptou e envolveu adolescente no narcotráfico (art. 40, VI, da Lei 11.343/06). Ademais, cabe lembrar ser impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu se dedicava a atividades criminosas, fazendo do narcotráfico meio de subsistência, o que se prova pela recente condenação pelo mesmo crime (processo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500432-46.2021.8.26.0571 - Controle 2021/000444

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS VINICIUS DE GOES FERRAZ

Data da Audiência:

09/02/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Luis Vinicius de Goês Ferraz. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Osny Benedito de Moraes Júnior e Anselmo dos Santos Carrascal arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c. c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c. c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, no dia 25 de março de 2021, por volta das 10h50min, na Rua Dr. Agides Ravaci, bem como na residência de nº 59, Jardim Nova Era, nesta cidade e Comarca de Itapetininga, agindo em concurso e com identidade de propósitos com o seu irmão, o adolescente Giovani de Goes Ferraz, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito: a) 23 (vinte e três) porções de "maconha", com peso líquido de 94,32g (noventa e quatro gramas e trinta e dois centigramas); b) 11 (onze) porções de "cocaína", na forma de "crack", com peso líquido de 3,0g (três gramas); c) 27 (vinte e sete) porções de "cocaína", com peso líquido de 6,29g (seis gramas e vinte e nove centigramas), e; d) 64 (sessenta e quatro) porções de "cocaína", com peso líquido de 15,00g (quinze

gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fls. 131) e apresentou defesa prévia (fls. 137/138). A denúncia foi recebida em 20/09/2021 (fls. 139/140) e o acusado foi pessoalmente citado (fls. 154). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de exibição/apreensão (fls. 13/14) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 87/90 e 99/101). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu negou a prática dos fatos. Disse que apenas iria consumir um cigarro de "maconha" com seu irmão (fls. 06). Interrogado em Juízo, o acusado refutou a acusação. Afirmou que se dirigiu até a casa de sua mãe, mas não a encontrou. Então, com o seu irmão, sentou-se na frente da residência para fumar um cigarro de "maconha". Dado instante, viu os policiais se aproximando. Não correu, pois não tinha motivo para isso. Os policiais acharam uma sacola com algumas porções de droga, que pertenciam ao seu irmão adolescente, em uma árvore. Mais tarde, o canil chegou e, quatro casas acima do local onde se encontrava, localizaram mais entorpecentes. Enfim, disse-se injustiçado e vítima de uma ação armada pela Polícia Militar. Ocorre que a prova é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento de rotina no bairro acima mencionado. Então, ao adentrarem a via pública citada, LUIS VINÍCIUS e seu irmão Giovani saíram em disparada. Diante da suspeita da conduta de ambos, os policiais resolveram abordá-los. LUIS VINÍCIUS, no momento da fuga, dispensou uma sacola plástica que continha 27 (vinte e sete) pinos de "cocaína" e 11 (onze) pedras de "crack". Com o acusado, ainda, foram encontrados R\$88,00 (oitenta e oito reais). Em seguida, na entrada da residência de nº 59, local onde o adolescente tentou se esconder, foi localizado um pé de maconha. No imóvel imediatamente ao lado, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de droga, com o auxílio do canil da guarda municipal, foram encontradas mais 23 (vinte e três porções) de "maconha" e outros 64 (sessenta e quatro) pinos de "cocaína", todas as porções embaladas de forma idêntica àquelas encontradas na sacola dispensada pelo acusado. Ante a inequívoca situação de flagrância, o acusado foi preso e conduzido a solo policial para as demais providências. Pois bem. Agora, os policiais voltaram a reproduzir, em detalhes, a tese acusatória. Não titubearam em afirmar que viram o acusado dispensar a sacola plástica com porções de drogas e que, com ele, foi apreendida quantia em dinheiro. Como se vê, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de quantia em dinheiro e as demais circunstâncias demonstram que o acusado possuía todas as porções para fins de tráfico. Portanto, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. As palavras das testemunhas foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito e, em conjunto com as demais provas, autorizam o decreto condenatório. Assim, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 38/41). Na segunda fase, a pena deverá ser agravada com fundamento no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Na terceira fase, a pena deverá ser aumentada, pois o réu cooptou e envolveu adolescente no narcotráfico (art. 40, VI, da Lei 11.343/06). Ademais, cabe lembrar ser impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu se dedicava a atividades criminosas, fazendo do narcotráfico meio de subsistência, o que se prova pela recente condenação pelo mesmo crime (processo 1501063-87.2021.8.26.0571). Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação de perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz. O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput c/c art. 40, VI da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código

Penal. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. Senão vejamos. I- DA NULIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR (COM O AFASTAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS NA RESIDÊNCIA). No caso dos autos, verifica-se que os policiais invadiram uma residência sem a autorização do morador e sem mandado de busca e apreensão domiciliar, apenas pelo fato de o adolescente Giovani ter corrido para dentro ao avistar a viatura. De acordo com a prova produzida, os policiais estavam realizando patrulhamento nas proximidades da residência, quando o adolescente (que estava junto com o réu), após ter avistado a viatura, teria corrido. Por esta razão, adentraram no local, o abordaram, fizeram buscas no local e no terreno vizinho, e localizaram drogas. Verifica-se que o argumento de o tráfico ser crime permanente não se aplica ao caso. No entanto, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores, o simples fato de o suspeito correr em direção à sua residência não justifica a entrada dos milicianos no local. O ingresso forçado em domicílio somente é legítimo, sem mandado judicial, desde que amparadas de fundadas razões, as quais devem ser devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso em concreto (artigo 240, §1º do CPP). Repise-se que o simples fato de o adolescente, ao avistar a viatura policial, ter se esvaído em direção à residência, não é uma justificativa suficiente para o ingresso forçado e não configura a necessária "fundada razão". Como podemos ver, num caso bem semelhante aos fatos em comento, o STJ decidiu: "Na hipótese sob exame, o acusado estava em local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas, quando, ao avistar a guarnição de policiais, refugiou-se dentro de sua casa, sendo certo que, após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (18 pedras de crack). Havia, consoante se demonstrou, suspeitas vagas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente, do local em que ele estava no momento em que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e em virtude de seu comportamento de correr para sua residência, conduta que pode explicar-se por diversos motivos, não necessariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora de mercancia ilícita de drogas" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.574.681 - RS (2015/0307602-3) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ). Logo, não se pode admitir que a simples constatação de situação de flagrante, após o ingresso, justifique a medida. Não seria coerente atribuir a um agente da segurança pública total arbitrariedade para, a partir da mera capacidade intuitiva, adentrar sem autorização, de maneira forçada na residência alheia. No caso em comento, a busca domiciliar, segundo os elementos colhidos na fase policial e judicial, ocorreu sem a prévia constatação da existência de flagrante delito. A subsequente (e sempre eventual) apreensão efetiva de drogas não tem o condão de suprimir a ilicitude que lhe antecedeu. Desta forma, o encontro e a consequente apreensão das drogas na residência e no

terreno vizinho são ilegais em sua origem, diante da manifesta violação da garantia constitucional insculpida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, remanescendo contra o réu tão somente a acusação de ter dispensado uma sacola contendo 27 (vinte e sete) pinos de "cocaína" e 11 (onze) pedras de "crack". II- DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Isso porque, não há nada de concreto que ligue o acusado às substâncias localizadas. Em primeiro lugar, com relação às substâncias foram localizadas em via pública, não há qualquer testemunha fora dos quadros policiais que indicasse ter Luís ter dispensado algo ao solo. Diante da dinâmica policial e suposta fuga dos suspeitos, é possível que os policiais tenham se confundido durante a rápida abordagem. De todo modo, não há qualquer prova que as substâncias ali encontradas se destinassem à venda. Os policiais não viram qualquer ato de mercancia, não viram o acusado em contato com qualquer pessoa e, ainda, não apreenderam em seu poder qualquer apetrecho para o tráfico. Na verdade, decidiram por abordá-lo somente pelo fato de ele ter saído em disparada quando avistou a viatura, o que, obviamente, não é conclusão, por si só, de que ele praticasse o tráfico de entorpecentes. Ademais,

ainda que considere legal a entrada nos domicílios onde o restante das substâncias foi encontrado, não há qualquer prova do vínculo do réu com essas substâncias (e, muito menos, com essas residências). O próprio policial ouvido declarou nem saber quem era o proprietário da residência e do terreno, afirmando que, quanto ao terreno, tratava-se de local abandonado. Assim, havendo dúvidas acerca da prática delitiva, o que atrai a incidência do princípio in dubio pro reo, deve o acusado ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV- TESES SUBSIDIÁRIAS. Por fim, caso não seja acolhida a tese anterior, a defesa requer: i) fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, considerando que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal; (ii) seja afastada a agravante pleiteada na denúncia, visto que o estado de pandemia em nada contribuiu ou influenciou para a prática delitiva; (iii) seja afastada a causa de aumento do art. 40 da Lei de Drogas, tendo em vista que não há qualquer prova de o réu estivesse influência sobre o menor ou de que praticassem o tráfico de drogas juntos; (iv) seja fixado o regime aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, “c”, § 3º, do CP, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – art. 387, § 1º, do CPP, requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão por uma das cautelares arroladas no art. 319 do CPP. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. LUIS VINÍCIUS DE GOES FERRAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06, c.c. o art. 61, inc. II, alínea “j”, do Código Penal, porque, no dia 25 de março de 2021, em período de anormalidade – Pandemia, por volta das 10 h e 50 min, na Rua Agides Ravacci, bem como na residência de n. 59, Jardim Nova Era, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com o irmão adolescente Giovani de Goes Ferraz, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e três porções de “maconha”, com peso de 94,32 gramas, onze porções de “crack”, com peso de 3,0 gramas, vinte e sete porções de “cocaína”, com peso de 6,29 gramas, e sessenta e quatro porções de “cocaína”, com peso de 15,0 gramas. Notificado, fls. 131, o Réu apresentou defesa preliminar,

fls. 137/138. A denúncia foi recebida, fls. 139/140, e o Réu, citado, fls. 154. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do Réu (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia; por outro lado, a Dra. Defensora insistiu na improcedência. É o relatório. DECIDO. Afasto a preliminar. De proêmio anoto que a única substância apreendida na residência foi o "pé de maconha", que pouco influirá na prova do comércio clandestino, mas, alegada a nulidade, passo a me manifestar. Segundo o art. 5º, inciso XI, a casa é asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito ou durante o dia, por determinação Judicial (grifo nosso). Portanto há autorização para ingresso em residências durante o dia ou noite em caso de flagrante delito. Segundo disposição do art. 283 "Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva". Oportuno ressaltar que os policiais não ingressaram na residência sem qualquer informação, de forma aleatória; tinham eles notícias de que o Réu e o adolescente vendiam entorpecentes, e, no dia dos fatos, o Acusado, ao ver a viatura, fugiu e dispensou algo, típica atitude de quem está na posse de substância ilícita e quer se desvencilhar da prisão; anote-se que a sacola foi recuperada e, no seu interior, havia porções de entorpecentes; com o Acusado os policiais apreenderam dinheiro. Assim, havia fundada suspeita para a abordagem e vistoria da casa, onde, de fato, encontraram um "pé de maconha", em situação de flagrante delito, na medida em que o crime de tráfico de entorpecentes é permanente. O caso concreto se amolda ao permissivo constitucional. A pretensão punitiva estatal é procedente. Análise a prova coligida. Nas fls. 13/14 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: R\$ 88,00; onze porções de "crack", com peso de 3,52 gramas; vinte e sete microtubos contendo "cocaína", com peso de 19,05; vinte e três porções de "maconha", com peso de 106,36 gramas; sessenta e quatro porções de "cocaína", com peso de 47,42 gramas e uma porção de "maconha", com peso de 4,49 gramas. No Laudo Pericial Definitivo em Substância Entorpecente, n. 97.871/2021, fls. 87/90, foi consignado o que segue: "Dos resultados. Item I - Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), constante na lista F2: Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores. Itens II, III e IV - Utilizando-se metodologias adequadas para análises dos referidos materiais, foram detectadas a presença da substância Cocaína, constante na lista F1: Lista das Substâncias Entorpecentes - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores.". No Laudo Pericial Definitivo em Substância Entorpecente, n. 109.793/2021, fls. 99/101, foi consignado o que segue: "Do resultado. Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), constante na lista F2: Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores".

Anselmo dos Santos Carrascal e Osny Benedito de Moraes Júnior, policiais militares, disseram que tinham recebido denúncias de tráfico de entorpecentes pelo Réu e pelo irmão, naquele local, as denúncias diziam que eles escondiam as drogas no mato. No dia dos fatos estavam em patrulhamento e, ao verem a viatura, correram, sendo que o Réu dispensou uma sacola; feita a abordagem, com o Acusado foi encontrado uma pochete com dinheiro; encontraram a sacola dispensada e no interior havia porções de entorpecentes. Observaram que o adolescente tinha entrado na casa e um dos policiais foi atrás, tendo observado um pé de "maconha" naquela residência; os policiais, com o auxílio de cães farejadores, encontraram outras porções de entorpecentes no terreno. Luís Vinícius de Góes Ferraz, Réu, ao ser interrogado, disse que tinha ido à casa da genitora para pegar dinheiro, e, ao sair, encontrou o irmão; estava com uma "bucha de maconha"; viu os policiais, mas não correu; os policiais abordaram-nos e disseram que tudo o que fosse encontrado seria do Réu; encontraram uma sacola com "cocaína" no topo da árvore e depois, com

cães, localizaram mais entorpecentes. Não dispensou sacola e as drogas encontradas no terreno não lhe pertencem. Confrontando-se a prova coligida, é inconteste que o Réu permanecia naquele local para atendimento de usuários de entorpecentes, pois, ao ver a viatura, fugiu e dispensou uma sacola, em cujo interior havia 27 pinos de "cocaína" e 11 pedras de "crack", drogas que, pela diversidade, quantidade e forma de partilha eram destinadas ao comércio. Por fim, houve apreensão de dinheiro, fruto de alienação pretérita, o que se infere das circunstâncias e da ausência de demonstração de ocupação lícita. O cultivo do pé de "maconha", na casa da genitora, conforme admitido pelo Réu (a propriedade da casa), demonstra que estava o Acusado preocupado com eventual abastecimento futuro de usuários, o que reforça a tese do comércio clandestino. Por outro lado, quanto aos entorpecentes localizados no terreno, não é possível concluir que pertencessem ao Réu, apesar da compatibilidade de embalagens, já que não foram vistos em deslocamento ao local e, tratando-se de ponto conhecido pela venda de drogas, é possível que pertencessem a outro vendedor. O emprego do adolescente não restou demonstrado, uma vez que apenas estava ao lado do Réu e apenas o Acusado tinha dispensado a sacola e, ademais, com o Réu houve apreensão de dinheiro. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo, guardava e mantinha em depósito substância entorpecente, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, guardar e manter em depósito, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto da Agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006: - Art. 59, "caput", do Código Penal: As circunstâncias judiciais são favoráveis, razão pela qual fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "j", não pode ser acolhida. Com efeito, a incidência da agravante da calamidade pública exige que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de circunstância que implique maior gravidade, e não há nexo de causalidade entre a ofensa ao bem jurídico e a pandemia do novo coronavírus. O Réu é menor de 21 anos, logo faz jus a atenuante. Todavia, na segunda etapa, a atenuante não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" - Art. 68, parte final, do Código Penal: Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, considerando-se a quantidade e a diversidade dos entorpecentes. Destarte, torno definitiva pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos

crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada, e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de final de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar LUIS VINÍCIUS DE GOES FERRAZ, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, por incidir no art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006. Sem condenação nas custas, em virtude da presunção de que não dispõe de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou do sustento da família. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de final de semana. Decreto o perdimento dos valores apreendidos. O Réu respondeu em liberdade ao processo e, neste momento, ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 09 de fevereiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA